

1500289-35.2021.8.26.0546

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAPHAELLO ALONSO GOMES CAVALCANTI

Comarca: Artur Nogueira

Foro: Foro de Artur Nogueira

Vara: 1ª Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... dos acusados (autoria) quando ao crime de tráfico, da mesma forma, restou fartamente demonstrada no conjunto probatório.

O investigado de polícia Flávio Roberto Caetano, tanto na fase inquisitiva quanto em Juízo, narrou que foi deflagrada a "OPERAÇÃO GUAÍQUICA", com escopo de combate ao tráfico de entorpecentes, onde, acompanhado pela Autoridade Policial e demais Policiais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Artur Nogueira

Foro de Artur Nogueira

Vara Única

Rua 13 de Maio, 140, Artur Nogueira-SP - cep 13160-170

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500289-35.2021.8.26.0546 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500289-35.2021.8.26.0546

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2212217/2021 - DEL.POL.ENGENHEIRO COELHO, 19458147 - DEL.POL.ENGENHEIRO COELHO, 376/21/910 - DEL.POL.ENGENHEIRO COELHO, 2212217 - DEL.POL.ENGENHEIRO COELHO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARCELO GABRIEL PEREIRA DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAPHAELLO ALONSO GOMES CAVALCANTI

Vistos.

BRUNO TIAGO SILVA e MARCELO GABRIEL PEREIRA DA SILVA foram denunciados e estão sendo processados como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, pelos seguintes fatos descritos na denúncia:

(...) Consta dos inclusos Autos de Prisão em Flagrante que, no dia 06 de agosto de 2021, pela manhã, na Rua Alcides Francisquete, n. 803, Jardim Eldorado, CEP 13160-000, em Engenheiro Coelho, nesta cidade e Comarca de Artur Nogueira/SP, BRUNO TIAGO SILVA, vulgo FÚRIA, e MARCELO GABRIEL PEREIRA DA SILVA, qualificados às fls. 02/04, 05/06, 07, 33/36, 41/43 e 44/45, tinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 31 (trinta e uma) pedras de crack pesando 0,6g (seis decigramas).

Consta, ainda, dos inclusos Autos de Prisão em Flagrante, que, em dia, horário e local incertos, mas antes de 06 de agosto de 2021, BRUNO TIAGO SILVA, vulgo FÚRIA, e MARCELO GABRIEL PEREIRA DA SILVA, qualificados às fls. 02/04, 05/06, 07, 33/36, 41/43 e 44/45, se associaram para praticar, reiteradamente, o tráfico de entorpecentes.

É dos autos que a Guarda Municipal e a Polícia Civil durante o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão expedido nos autos 1500725-22.2021.8.26.0666, investigação prévia em que constatou-se que BRUNO TIAGO SILVA, vulgo FÚRIA, era integrante do PCC, adentraram mediante arrombamento a casa em que estavam os acusados que era de propriedade de BRUNO e, em revista, identificaram, na mesa do imóvel 01 (uma) pedra de crack, R\$ 310,00 (trezentos e dez reais), além de uma balança de precisão e 980g (novecentos e oitenta gramas) de farinha de trigo, sendo que tudo isto estava ao livre acesso de ambos os denunciados.

Durante as buscas, BRUNO TIAGO SILVA, vulgo FÚRIA saiu do banheiro da casa, no qual a descarga fora acionada, e os policiais puderam perceber então que a janela daquele cômodo era voltada para o quintal da casa vizinha.

A força policial rumou para o imóvel vizinho e, com a permissão da proprietária, localizaram em seu quintal, próximo à janela do banheiro da casa de Bruno, 30 (trinta) outras pedras de crack devidamente embrulhadas.

O acusado MARCELO GABRIEL PEREIRA DA SILVA confessou a propriedade dos entorpecentes.

Os denunciados foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Engenheiro Coelho para as providências de praxe.

A grande quantidade de entorpecente localizada pela Polícia Militar, Guarda Municipal e Polícia Civil, a alta soma de dinheiro encontrada por ela, a ausência de explicação comprovada acerca do dinheiro, a balança de precisão e os 980g (novecentos e oitenta gramas) de farinha de trigo localizados são fortes indícios de que os acusados cometeram os crimes a imputados eles nesta peça.. (...)

Os acusados foram notificados (fls. 124 e 154) e apresentaram defesa preliminar (fls. 161/163 e 169/174).

A denúncia foi recebida no dia 08/11/2021 (fl. 176).

Os acusados foram citados (fls. 203 e 204).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e interrogados o réu Marcelo. O réu Bruno não pode ser interrogado uma vez que não compareceu ao Fórum e, apesar de ter se conectado ao link da audiência, não conseguiu manter contato de áudio.

Em alegações finais orais, o representante do Ministério Público postula a procedência da pretensão punitiva estatal, com a condenação dos acusados nos termos da denúncia. As defesas, por seu turno, requerem a absolvição por insuficiência de prova ou desclassificação do delito, bem como a fixação da pena no mínimo legal, com aplicação da minorante prevista no §4º, do artigo 33 da LAD, e regime inicial benéfico.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

Inicialmente, ressalto que não se implementou qualquer prazo prescricional, não há preliminares a serem apreciadas, nulidades a serem reconhecidas de ofício, tampouco prejudiciais, pelo que passo à análise do mérito.

No mérito, a materialidade do delito de tráfico de drogas foi constatada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06/14), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 22), Laudo toxicológico (fls. 213/215) bem como pela prova oral colhida.

A responsabilidade criminal dos acusados (autoria) quando ao crime de tráfico, da mesma forma, restou fartamente demonstrada no conjunto probatório.

O investigado de polícia Flávio Roberto Caetano, tanto na fase inquisitiva quanto em Juízo, narrou que foi deflagrada a "OPERAÇÃO GUAÍQUICA", com escopo de combate ao tráfico de entorpecentes, onde, acompanhado pela Autoridade Policial e demais Policiais Cíveis e GCMS de Engenheiro Coelho e de Mogi Mirim, juntamente com uma cadela farejadora, de posse de um mandado de Busca e Apreensão se dirigiram ao endereço Rua Amaro Franco de Oliveira, Nº 803 -Jardim Eudorado II, nesta Urbe em

desfavor da residência de "BRUNO", "FURIA" e outro. Adentraram o local, onde havia três casinhas sendo todos vistoriados. O local fora vistoriado pela cadela farejadora, no qual apenas encontraram uma pequena quantia de invólucro de drogas e uma balança de precisão, sobre a mesa onde se encontravam os dois indivíduos "BRUNO" e "MARCELO". Entretanto, como ambos demoraram para abrir a porta ouviram o som de descarga e a porta do banheiro fechada. Após, abriram esta porta do banheiro e notaram que a janela dele dava para o quintal do vizinho. Solicitaram para a vizinha, a qual autorizou, adentarem em seu imóvel, no qual localizaram em seu quintal, próximo à janela do banheiro um invólucro plástico (aparentando ser sacola de supermercado), onde estavam em seu interior, a quantidade de 31 "PEDRAS" aparentando ser "CRACK", devidamente embrulhadas. A princípio nenhum dos dois quis assumir a propriedade das substâncias e entorpecentes. Ambos foram conduzidos à delegacia, onde o autor MARCELO assumiu a propriedade das drogas. Que o réu Bruno se encontrava no banheiro quando entraram no local. Que acredita que o réu Marcelo assumiu a propriedade das drogas por medo de Bruno.

O Guarda Civil Municipal Tiago Benedicto confirmou a versão do Policial Militar. Afirmou que deu apoio à "OPERAÇÃO GUAÍQUICA", com escopo de combate ao tráfico de entorpecentes, onde, acompanhado pela Autoridade Policial e demais Policiais Civis e GCMs de Engenheiro Coelho e de Mogi Mirim, deram cumprimento a um mandado de Busca e Apreensão. Que no local os indivíduos "BRUNO" e "MARCELO". demoraram para abrir a porta, tendo de ser desobstruído o obstáculo, onde ao adentrar, ouviram o som de descarga e viram a porta do banheiro fechada. Após, abriram a porta do banheiro e notaram que a janela dele dava para o quintal do vizinho. Que no quintal, próximo à janela do banheiro dos réus encontraram um invólucro plástico (aparentando ser sacola de supermercado), onde estavam em seu interior, a quantidade de 31 "PEDRAS" aparentando ser "CRACK", devidamente embrulhadas. Que o autor MARCELO assumiu a propriedade das drogas. Que o réu Bruno estava no banheiro. Que Bruno negou ter ciência das drogas.

O réu Bruno, na fase inquisitiva, afirmou ser amigo do Marcelo. Que há dois dias havia deixado o Marcelo morar em sua casa, mas não sabia que Marcelo estava traficando drogas e não sabia que ele estava guardando em sua casa. Que quando os policiais chegaram em sua casa, MARCELO dispensou toda a droga para o lado externo da casa, mas ainda assim os policiais acharam a droga. Que a balança bem como os plásticos e demais materiais utilizados para a pesagem e embalagem da droga pertencem a MARCELO.

Não foi interrogado em Juízo, tendo em vista que, apesar de cientificado de que deveria comparecer ao Fórum caso não conseguisse conexão, não compareceu ao Fórum e não conseguiu estabelecer conexão de áudio com o Juízo. Ainda, segundo consta da gravação, sua defensora ainda afirmou que lhe recomendou que comparecesse ao seu escritório, não o tendo feito, e o Juízo tentou de todas as formas estabelecer contato, sem sucesso. Desta forma, a versão que se tem é a apresentada na fase inquisitiva de negativa de autoria delitiva.

O réu Marcelo, por sua vez, na delegacia confirmou a propriedade da droga e informou que fazia aproximadamente 2 (dois) meses que está traficando drogas, sendo que compra essa droga na cidade de Cosmópolis para posteriormente revender. Que fazia alguns dias que estava morando na casa de Bruno, todavia o Bruno não sabia que ele estava vendendo drogas. Que na data dos fatos, quando percebeu os a presença dos policiais na porta da casa dele, de imediato dispensou toda a droga pelo vidro do banheiro. Que a balança bem como os plásticos e demais materiais utilizados para a pesagem e embalagem são de sua propriedade também.

Em Juízo, negou a versão dos fatos, afirmando que foi até o local apenas para comprar maconha. Que Bruno era traficante e dispensou as drogas pela janela do banheiro. Que na delegacia assumiu a propriedade das drogas por ter sido ameaçado por Bruno, integrante do PCC.

Verifica-se que a versão exculpatória apresentada pelo réu Bruno e corroborada pelo réu Marcelo não se mostra verossímil. Ainda que, de fato, Marcelo estivesse residindo na casa de Bruno a pouco tempo, é certo que não há como se acreditar que ele não realizasse a traficância juntamente a Marcelo ou ao menos tivesse ciência do depósito e armazenamento dos entorpecentes no local. Em verdade, as testemunhas

narraram que o réu Bruno se encontrava no banheiro quando dispensou as drogas, e ainda foram apreendidos petrechos para o tráfico no local, como uma balança de precisão, diversos sacos para armazenamento de entorpecentes, os quais encontravam-se à vista no imóvel, e não escondidos por Marcelo sem a ciência de Bruno. Assim, tratando-se de delito de conduta mista alternativa, ainda que Bruno não tenha efetivamente realizado a mercancia, o mero fato de ter participado do depósito e armazenamento dos entorpecentes em sua residência é suficiente para que incida no tipo penal.

Importante salientar que os depoimentos dos policiais e guardas municipais que participaram da diligência são válidos e suficientes para embasar uma sentença condenatória, mormente pelo fato de não haver nenhum indício de que faltaram com a verdade para legitimar suas ações ou para prejudicarem o acusado.

Quanto aos depoimentos de servidores da segurança pública, presume-se a imparcialidade na execução de seus trabalhos, até porque não há qualquer indício de desavenças por parte dos agentes em relação à ré, que os motivasse a construir todo um plano tão somente para incriminar pessoa inocente. Acerca da validade dos depoimentos de policiais, ensina nossa jurisprudência, verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. O entendimento neste Tribunal Superior é o de que "o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (REsp n. 1.574.681/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe de 30/5/2017).

2. No caso em apreço, contudo, o Tribunal de origem concluiu que havia fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicílio do acusado em razão de ele ter dispensado, antes de correr em direção ao interior do imóvel, uma sacola onde foram encontrados os 26 papéletes de maconha, conduta suspeita que, associada às demais circunstâncias, motivou a abordagem dos policiais. Inexiste, portanto, a nulidade alegada pelo ora agravante. Precedente.

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

4. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada

flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroborados por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

A quantidade de drogas apreendidas, a forma em que se encontravam acondicionadas (31 (trinta e uma) pedras de crack pesando 0,6g (seis decigramas), além dos apetrechos apreendidos e da narrativa do réu Marcelo, bem como as circunstâncias em que se deu a prisão dos réus, os quais foram objeto de prévias investigações ensejando a expedição de mandado de busca e apreensão para o local, não deixam dúvidas de que se tratava de entorpecente destinado ao tráfico.

Não há nos autos qualquer indicativo de que os guardas civis teriam qualquer intenção de prejudicá-los.

Vê-se, em verdade, que as alegações extrajudiciais dos réus apenas tentam afastar a responsabilidade criminal de Bruno, imputando-a totalmente a Marcelo. Já a versão apresentada por Marcelo em Juízo também não merece guarida, vez que não se mostra comum que usuários se dirijam ao interior da residência de traficantes para adquirir entorpecentes. Aliás, sequer havia no local o entorpecente por ele supostamente consumido, maconha.

Se não bastasse, o fato de os acusados eventualmente serem usuários de entorpecente não afasta a possibilidade do delito de traficância. Pelo contrário, não é raro que usuários passem também a comercializar entorpecentes justamente para garantir o próprio vício, acrescentando-se, por oportuno, que uma conduta não exclui a outra: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (RJTJSP 101/498).

Ainda, o fato de eventualmente também possuírem atividade lícita, ainda que com registro em carteira, em nada interfere na possibilidade de exercer concomitantemente a traficância.

Sendo assim, pela lição de Júlio F. Mirabete, "indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado" (in Processo Penal - 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 344)

A prova acusatória, portanto, demonstrou satisfatoriamente a responsabilidade penal dos réus, de modo que não há como se acolher a pretensão absolutória da Defesa, que não conseguiu demonstrar a veracidade de suas alegações, como já consignado anteriormente.

Já no tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas, de rigor a absolvição dos réus.

No caso, a organização, a pré-ordenação dolosa, a estabilidade e a permanência da sociedade criminosa, indispensáveis para a tipificação do delito capitulado no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, não restaram cabalmente demonstradas.

Ainda que os réus tenham sido surpreendidos praticando juntos o tráfico de drogas, tal fato não é suficiente para, isoladamente, caracterizar a associação para o tráfico, vez que não foram trazidos outros elementos de prova que demonstrassem o vínculo permanente e autônomo entre eles com o intuito de comercializar entorpecentes.

Os policiais militares e guardas civis responsáveis pela prisão não forneceram informações concretas nesse sentido, apenas denotaram terem participado do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em operação policial. Mas não indicaram prévias investigações quando ao liame subjetivo dos réus.

A união anterior e perene não pode ser provada apenas pelas circunstâncias da prisão e da apreensão de drogas. Imprescindíveis são as provas da combinação de vontades e vínculo associativo antes do flagrante.

O que se tem nos autos é a típica situação de concurso de agentes que, por si só, não caracteriza o delito associativo.

A jurisprudência já se posicionou sobre o tema:

"Associação ao tráfico Absolvição Admissibilidade Inexistência de prova segura de que os réus mantinham associação estável para a prática da venda ilícita de entorpecentes Recurso parcialmente provido para absolver os apelantes." (TJ/SP, Apelação Criminal nº 0001875-83.2016.8.26.0506, Des. Relator Miguel Marques e Silva, Data do Julgamento 23/08/2018).

Destaque-se, no mesmo sentido, a lição de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas" (Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, página 335):

"Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do artigo 35 (antigo artigo 14 da Lei Federal nº 6.368, de 1976) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum. Não existe a forma culposa."

Assim, outra solução não resta senão a absolvição dos réus da imputação do artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

Caracterizadas a autoria e a materialidade delitivas apenas o tráfico de entorpecentes, a procedência parcial da denúncia é medida que se impõe.

Demonstradas, pois, a ocorrência do crime e a responsabilidade criminal dos acusados, inexistentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, passo à fixação da pena, em observância ao disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343 de 2006.

Réu Marcelo

Na primeira fase, verifico que o acusado é tecnicamente primário. Outrossim, quanto às demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, nada há de relevante, pois a culpabilidade, entendida como grau de reprovação que merece pela prática do crime, apresenta-se em grau mediano e as circunstâncias, as consequências, bem como os motivos do crime são típicos de delitos dessa natureza. Ademais, nade se apurou acerca de sua personalidade e conduta social, e a vítima é a coletividade. No quer atine às circunstâncias preponderantes do artigo 42 da LAD, a natureza da droga "crack" deve ser considerada para eleição da fração de redução na terceira fase, sob pena de bis in idem.

Assim, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06 c.c. o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, não existem agravantes e presente a atenuante da menoridade relativa, contudo, frente à Súmula nº 231 do c. STJ, deixo de reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Não há causas de aumento de pena. Contudo, presente a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que o acusado é primário, possui bons antecedentes, e não há nos autos elementos concretos a indicar que se dedique a atividades criminosas. Por outro lado, a natureza do entorpecente apreendido - crack -, demasiadamente gravosa à saúde humana e colabora por incrementar a necessidade de serviços de saúde, deve ser considerada para eleição da fração redutora, a qual aplico no patamar de 1/2, tornando a pena definitivamente fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

O regime de cumprimento de pena suficiente e necessário é o aberto, tendo em vista o quantum de pena, a primariedade e os bons antecedentes do agente (art. 33, do CP).

Por sua vez, com relação à almejada substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a Resolução nº 5 do Senado, publicada em 16.02.2012, com efeito erga omnes, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", inserida no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, consagrando o princípio constitucional da individualização da pena. Desse modo, cabe ao Julgador verificar a possibilidade de aplicação das penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 e seguintes do Código Penal.

Nessa linha, insta consignar entendimento recentemente exarado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o qual, em sede de julgamento do HC 118.533, por maioria de votos, decidiu pelo afastamento da hediondez do delito de tráfico privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06). Assim, tendo em vista as condições pessoais do acusado (tecnicamente primário) e natureza do ilícito praticado (sem violência ou grave ameaça), consoante acima observado, é o caso de conversão da pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos - por igual período ao da pena privativa de liberdade, devendo ser descontado o tempo de fática reclusão -, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a serem definidos pelo Juízo da Execução.

Ante a substituição da pena privativa de liberdade não há que se falar em sursis penal (art. 77 do CP).

Réu Bruno

Na primeira fase, verifico que o acusado é tecnicamente primário. Outrossim, quanto às demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, nada há de relevante, pois a culpabilidade, entendida como grau de reprovação que merece pela prática do crime, apresenta-se em grau mediano e as circunstâncias, as consequências, bem como os motivos do crime são típicos de delitos dessa natureza. Ademais, nade se apurou acerca de sua personalidade e conduta social, e a vítima é a coletividade. No quer atine às circunstâncias preponderantes do artigo 42 da LAD, a natureza da droga "crack" deve ser considerada para eleição da fração de redução na terceira fase, sob pena de bis in idem.

Assim, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06 c.c. o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, não existem agravantes ou atenuantes.

Não há causas de aumento de pena. Contudo, presente a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que o acusado é primário, possui bons antecedentes, e não há nos autos elementos concretos a indicar que se dedique a atividades criminosas. Por outro lado, a natureza do entorpecente apreendido - crack -, demasiadamente gravosa à saúde humana e colabora por incrementar a necessidade de serviços de saúde, deve ser considerada para eleição da fração redutora, a qual aplico no patamar de 1/2, tornando a pena definitivamente fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

O regime de cumprimento de pena suficiente e necessário é o aberto, tendo em vista o quantum de pena, a primariedade e os bons antecedentes do agente (art. 33, do CP).

Por sua vez, com relação à almejada substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a Resolução nº 5 do Senado, publicada em 16.02.2012, com efeito erga omnes, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", inserida no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, consagrando o princípio constitucional da individualização da pena. Desse modo, cabe ao Julgador verificar a possibilidade de aplicação das penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 e seguintes do Código Penal.

Nessa linha, insta consignar entendimento recentemente exarado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o qual, em sede de julgamento do HC 118.533, por maioria de votos, decidiu pelo afastamento da hediondez do delito de tráfico privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06). Assim, tendo em vista as condições pessoais

do acusado (tecnicamente primário) e natureza do ilícito praticado (sem violência ou grave ameaça), consoante acima observado, é o caso de conversão da pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos - por igual período ao da pena privativa de liberdade, devendo ser descontado o tempo de fática reclusão -, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a serem definidos pelo Juízo da Execução.

Ante a substituição da pena privativa de liberdade não há que se falar em sursis penal (art. 77 do CP).

Por serem parcas as informações acerca da situação financeira dos réus, fixo o valor do dia-multa no seu mínimo legal, a ser atualizado pelo salário-mínimo da data dos fatos até o momento do seu efetivo pagamento.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, eis que não há nos autos qualquer informação acerca do comportamento carcerário dos acusados no período em que estiveram presos provisoriamente. De fato, ofende o princípio constitucional da isonomia, insculpido no artigo 5º, da CF, exigir-se do condenado definitivo a comprovação de que possui bom comportamento carcerário para que possa progredir de regime, enquanto que ao sentenciado provisório permite-se a progressão sem qualquer demonstração de sua conduta durante o período em que permaneceu custodiado.

Assim, com o fito de evitar tal distorção, e fazendo-se uma interpretação sistêmica do ordenamento jurídico (artigo 112 da LEP), entendo que a aplicação do disposto no artigo 387, §2º, do CPP, fica condicionada à comprovação nos autos acerca do comportamento do acusado no estabelecimento prisional onde permaneceu detido.

Ausentes documentos que atestem tal situação, não seria mesmo o caso de se progredir o réu de regime fixado nesta sentença.

Ademais, fora fixado regime inicial aberto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO BRUNO TIAGO SILVA e MARCELO GABRIEL PEREIRA DA SILVA, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cada qual no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma da fundamentação. Ainda, ABSOLVO ambos os réus da prática do delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Em vista do regime inicial e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como ausentes os requisitos para a segregação cautelar neste momento, concedo aos réus o direito de apelar em liberdade. Assim, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO em favor do réu MARCELO GABRIEL PEREIRA DA SILVA, o qual encontra-se recluso preventivamente por este feito. O réu BRUNO já encontra-se solto em virtude de anterior HC.

Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal. Eventual gratuidade de justiça deverá ser analisada pelo Juízo da Execução.

Declaro o perdimento em favor da União Federal dos valores apreendidos nos autos, pois não comprovada a origem lícita.

Fica autorizada a incineração das drogas apreendidas se acaso tal providência ainda não tiver sido realizada, nos termos do art. 32 e parágrafos da Lei 11.343/06.

Não há que se falara em reparação de danos à vítima (CPP, art. 387, IV).

Ao defensor nomeado arbitro honorários advocatícios, no valor da tabela da DPE, devendo ser expedida a certidão, com celeridade.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD; oficie-se ao e. TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da CF; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente; e proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do artigo 686, do Código de Processo Penal.

Intimados os presentes.

Publique-se. Cumpra-se.
Artur Nogueira, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA